

1500795-96.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500795-96.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2156773/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25462187 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2156773 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

CLAUDINEI PAES DA CRUZ

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", VI e Art. 35 "caput" todos do(a)

SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

05/09/2022

Réu Preso

Em 05 de setembro de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu CLAUDINEI PAES DA CRUZ, bem como o seu Defensor Técnico, DR. André Luiz Araujo Marigo OAB 386195/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Luciano Donizeti Rodrigues da Silva (PM) e Gregori Moraes de Oliveira (PM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada

por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu CLAUDINEI PAES DA CRUZ, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, eis que: 1) no dia 8 de junho de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, se associou com o adolescente Kelven Henrique de Almeida Santos (13 anos de idade), para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; e 2) no dia 8 de junho de 2021, por volta das 14h, na Rua Pedro Domingues Menke, nº 180 - Vila Angélica, nesta cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustado, agindo em concurso, com unidade de desígnios, identidade de propósitos com o adolescente Kelven Henrique de Almeida Santos (13 anos de idade), trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 6 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 3,95 gramas, e 34 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 32,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da denúncia, na data dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito contando com a participação do adolescente e, para tanto, ambos permaneciam juntos no local da abordagem aguardando usuários para promover a venda oportuna. Na prática delitiva, porquanto associados, CLAUDINEI e Kelven faziam uso da residência do adolescente, onde guardavam em mantinham mais entorpecentes em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros. Policiais Militares estavam em serviço quando receberam informação dando conta de que CLAUDINEI e o adolescente estavam vendendo drogas em frente ao "Bar do Gordo", local conhecido pela intensa prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Assim é que, na posse da descrição das vestes de ambos, os Policiais se deslocaram para o endereço fornecido e, lá chegando, avistaram os dois indivíduos e efetuaram a abordagem. Na ocasião, indagados, CLAUDINEI e o adolescente admitiram a prática delitiva. Em revista pessoal, os Policiais encontraram 6 "pinos" de cocaína dentro da boca do denunciado e outras 2 porções de cocaína escondidas nas vestes íntimas de Kelvin, drogas que lhes pertenciam e estavam destinadas à venda. O réu foi notificado (fls. 83) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 91/92). Assim, por decisão proferida no dia 23 de agosto de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 93/94). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição do acusado, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 25/31, bem como Certidões a fls. 32/34. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido ministerial comporta parcial procedência, absolvendo-se o réu da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:" (grifos aditados). No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas - de que trata o art. 29 do Código Penal - com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e

doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro, denotando vínculo associativo e não mero concurso eventual. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...)" (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Além disto, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)" (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)" (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que o acusado e o adolescente exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que praticavam ou pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse possível verificar que o tráfico não seria exercido pontualmente, tampouco foram localizados instrumentos de preparação ou anotações de contabilidade, revelando o caráter não episódico da traficância. Portanto, diante da ausência de provas em relação ao animus associativo entre o réu e a adolescente, imperiosa a absolvição deles no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07), pelo auto de constatação preliminar (fls. 10/11), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 76/80) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 05), manteve-se silente. Em juízo, disse que fazia 10 meses que estava em liberdade, que não queria mais mexer com crime, mas ainda usava maconha e cocaína. Foi até o local para comprar droga porque ali é melhor e mais barato. Foi com o disk moto até próximo ao bar do gordo e visualizou dois

adolescentes, eles disseram que a policia estava no bairro, mas disse que era rápido e deu R\$60,00 para o adolescente Gustavo, que voltou rápido com a droga. Quando pegou a droga os policiais estavam subindo, daí colocou a droga na boca, ocorreu que Kelven também entrou no bar. O adolescente Gustavo também foi abordado, mas foi liberado. Foi abordado, informou que estava com os pinos e que tinha comprado com o adolescente que eles tinham acabado de liberar. Disse que estava ali apenas para comprar droga e eles perguntaram sobre suas passagens e depois disseram que o levariam preso pois estava em local suspeito e com droga. Abordaram Kelven, indagaram se ele tinha mais droga e ele disse que tinha. Adentraram na casa de Kelven e saíram com mais droga. Nega que tenha admitido o trafico para os policiais e até indicou de quem comprou as drogas. No Santa Rita a porção é 30 e ele comprou

por 10 reais. Não sabe porque os policiais relataram no sentido de que ele confessou. Não conhecia esses policiais, estava trabalhando com Sr. Nelson e não precisa estar vendendo droga. Tem uma namorada de 17 anos e uma filha recém-nascida. O réu ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, negou os fatos. Entretanto a negativa não prospera. O réu disse que foi até o local para adquirir entorpecente, versão inconsistente já que o bairro em que reside (Jardim Santa Rita) tem alta incidência de tráfico, sendo desnecessário que se deslocasse até bairro distante a fim de suprir seu uso. Ademais houve denúncia anônima que apontava o réu e os milicianos ouvidos foram categóricos em afirmar que o réu confessou informalmente o crime de trafico de entorpecentes. O Policial Militar Luciano Donizete Rodrigues da Silva, em sede policial (fls. 03), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Angélica, quando receberam denúncia anônima que dois sujeitos estavam vendendo drogas em frente ao "Bar do Gordo", local conhecido pela venda de drogas. A denúncia precisava as características, descrevendo a bermuda e camiseta de ambos sujeitos. Ao chegarem ao local dos fatos, avistaram os dois sujeitos com as vestes semelhantes a denúncia, sendo que os dois foram abordados. Indagados, ambos confessaram a venda de drogas. O CB PM Gregori realizou a revista pessoal, onde encontrou com CLAUDINEI 6 pinos de cocaína no interior de sua boca e, com o adolescente Kelven, foi encontrado 2 porções de aricanduva tipo cocaína dentro da sua cueca. O adolescente falou que em sua casa havia mais drogas e que deslocaram até a residência dele, onde, com a autorização da mãe do adolescente, encontrou 32 porções de Aricanduva tipo cocaína, semelhantes a encontrada com ele. Em juízo, a testemunha disse que receberam denuncia anônima de que no bar do gordo havia dois indivíduos comercializando e deu as vestimentas dos indivíduos. Foram ao local, identificaram os indivíduos e eles ao avistarem a viatura rapidamente adentraram ao bar. Em busca pessoa com Claudinei foram localizados 6 pinos que estavam na boca do réu e com Kelven havia dois pinos escondidos em sua cueca. Na casa do adolescente, após ser franqueada a entrada pela mãe do adolescente foram encontradas mais 32 porções do tipo Aricanduva, idênticas as que estavam com o adolescente. Não conhecia os indivíduos. O acusado não estava vendendo no momento da abordagem. Não foi pego dinheiro com eles. A casa de Kelven fica a uns 200 metros do local dos fatos e a droga estava na garagem no local indicado pelo adolescente. Claudinei morava em outro bairro. O réu confessou o trafico e disse que estava passando necessidade, pegou o kit no dia anterior e estava ali para vender o restante. Quando se aproximaram o réu estava junto do adolescente e em momento algum disse que estava ali para comprar droga do adolescente. Não aparentava estar sob efeito de substancia entorpecente. Convergindo em mesmo sentido, o também Policial Militar Gregori Moraes de Oliveira, em sede policial (fls. 04), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, a testemunha disse que estavam em patrulhamento de força tática quando receberam denuncia de que dois indivíduos estariam realizando o comercio no bar do gordo, sendo repassadas as características. Foram ao local, identificaram o réu e o adolescente, sendo com o réu encontrados 6 pinos de cocaína e com Kelven 2. Na casa do réu foram encontradas 32 porções de cocaína. A droga foi encontrada na casa de Kelven, que era idêntica a encontrada com Kelven. Os dois estavam parados quando foram vistos e quando viram a viatura ingressaram no bar. O réu confessou o trafico e os 6 pinos seriam o que teria sobrado da venda do dia anterior. Em momento algum alegou que era para uso. Claudinei mora bem distante, do outro lado da cidade, no bairro Santa Rita, onde também há incidência de trafico. Nenhum dos dois aparentava estar sob efeito de substancia entorpecente. O denunciante não quis se identificar e provavelmente tratava-se de morador. Não conhecia os réus dos meios policiais. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor

probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas em poder do réu e com o adolescente, bem como o restante na casa do último; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 76/80), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações, forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 4) a localização do acusado e do adolescente nas mesmas condições da delação apócrifa descrevia; e 5) a informação dos policiais de que, informalmente, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, aprendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e

direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTCrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 76/80) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo–, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. De fato, observo que o acusado ostenta duas condenações criminais definitivas, de modo que utilizarei uma delas (Proc. 3009749-10.2013.8.26.0624 – fls. 33) como Maus antecedentes, e a outra como agravante de reincidência, sem que se incorra em bis in idem. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do E. TJSP: “é plenamente viável o rateio das duas condenações definitivas do réu João entre antecedentes e reincidência, sem incidir em bis in idem, permitindo a correta individualização de sua pena, de acordo com todas as circunstâncias do caso concreto.” (TJSP; Apelação Criminal 1500174-20.2021.8.26.0544; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021). De igual modo, entende o C. STJ (“É firme o entendimento desta Corte Superior de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os Maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes” – HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018). Por tal razão, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é de rigor, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, presente a agravante de reincidência, que, aliás, é específica (Proc. nº 0000337-66.2016.8.26.0571, fls. 32), agravo sua pena na fração de 1/5, gerando a reprimenda legal de 07 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa. Finalmente, considerando que o crime foi praticado com o envolvimento adolescente, tem-se por necessária a incidência da causa de aumento de que trata o art. 40, inciso VI, da

Lei de Drogas. E, portanto, aumento sua pena em 1/6, gerando a reprimenda legal de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de réu reincidente e de maus antecedentes, resta inviabilizada a concessão da benesse em questão. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fulcro no artigo 33, § 2º, a, do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando a quantidade de pena aplicada. As mesmas motivações acima expostas impedem a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu CLAUDINEI PAES DA CRUZ, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; e 2) absolver o acusado da imputação de prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar do acusado. E mais, considerando os maus antecedentes e a reincidência específica do acusado, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei". Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 84). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA